

刑法
No75

R6-4

(配点: 4)

月 日

月 日

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 医師ではない甲は、女性Aに対し、医学的に必要とされる措置を採らず、身体に重大な傷害を生じさせかねない危険な方法で豊胸手術を行った。Aが豊胸手術に伴う身体傷害についてあらかじめ承諾していた場合、甲に傷害罪が成立することはない。
- イ. 甲は、自動車の転落事故を装いAを自殺させて保険金を得る目的で、極度に甲を畏怖していたAに対し、暴行・脅迫を加え、岸壁上から自動車ごと海中に転落して自殺することを執ように要求し、Aをして甲の命令に従う以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせてA自ら岸壁上から自動車ごと海中に転落させたが、その後、Aが岸壁上に逃れて生き延びた。この場合、A自らが死亡する現実的危険性の高い行為を選んだから、甲に殺人未遂罪が成立することはない。
- ウ. 甲は、4歳の実子Aから甲に殺害されることの承諾を得て、殺意をもってAを包丁で刺殺した。この場合、Aが殺害されることを承諾しているから、甲に殺人罪が成立することはない。
- エ. 甲は、妊娠している妻Aと話し合い、その承諾を得て、薬物を使用して堕胎させた。この場合、堕胎についてAが承諾をしているから、甲に不同意堕胎罪が成立することはない。
- オ. 甲は、半日以内にAに返す約束でAの承諾を得て、A所有の自動車をAから借り受けたが、同車を運転するうちに、約束どおり同車をAに返すことが惜しくなり、Aに無断でそのまま10日間にわたり同車を乗り回した。この場合、甲に横領罪が成立することはない。

No75

同意

正答率

R6-4

正解

ア 2

イ 2

ウ 2

エ 1

オ 2

77%

ア 誤っている

東京高判平9.8.4は、本記述と同様の事案において、被害者の「承諾があるとしても、もとより違法性を阻却しない」としている。その理由として、「被告人が被害者に対して行った医療行為は、身体に対する重大な損傷、さらには生命に対する危難を招来しかねない極めて無謀かつ危険な行為であって、社会通念上許容される範囲・程度を超えて、社会的相当性を欠く」としている。よって、本記述においては、甲に傷害罪が成立し得る。

イ 誤っている

最決平16.1.20(百選I73事件)は、「被告人は、以上のような精神状態〔注：被告人の命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態〕に陥っていた被害者に対して、本件当日、漁港の岸壁上から車ごと海中に転落するように命じ、被害者をして、自らを死亡させる現実的危険性の高い行為に及ぼせたものであるから、被害者に命令して車ごと海に転落させた被告人の行為は、殺人罪の実行行為に当たるといふべきである」としている。よって、本記述においては、甲に殺人未遂罪が成立し得る。

ウ 誤っている

大判昭9.8.27は、本記述と類似の事案において、殺人罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、同意殺人罪が成立するためには、被殺者の有効な被殺意思が必要であり、そのためには、死の意味を理解し得る精神能力が必要であるところ、それを欠く者には有効な同意を認めることはできないことを挙げている。よって、本記述においては、4歳のAは死の意味を理解し得る精神能力を欠いているから、その承諾があったとしても、甲に殺人罪が成立する。

エ 正しい

女子の承諾は自由かつ真意に基づくものであることを要するところ(仙台高判昭36.10.24)、本記述においては、甲は、妊婦である妻Aと話し合ってその承諾を得ている以上、不同意堕胎罪(215条1項)は成立せず、同意堕胎罪(213条前段)が成立する。

オ 誤っている

大阪高判昭46.11.26は、短時間の使用を許された自動車を8日間乗り回した事案において、横領罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、そのような利用は権利者による許容ということが考えられないことを挙げている。よって、本記述においては、Aは、半日を超える自動車の使用を許容していないから、甲に横領罪が成立し得る。